



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבוים

תיק מס': 138/04

בענין:

אלקין חיים וברוריה
מרח' הקיבוצים 9, קרית-חיים

התובעים

נ ג ד

1. אונגר ישראל ויוסף
ע"י ב"כ עוה"ד א.שמר ואח' מרח' מנחם בגין 90
תל-אביב
2. רטר יעקב
ע"י ב"כ עוה"ד ש. שולשטיין
ת.ד. 2400, קרית-מוצקין
3. עוה"ד דניאל שפירא (ב"כ של אביטל עדנה)
מרח' הרב קוק 20, קרית-מוצקין

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. בעלים של דירה בבית משותף הגישו תביעה לאשר בניית גדר אבן החוצה את החצר העורפית של הבית המשותף, להכיר בחלוקה הקיימת דה פקטו ולהורות כי כל בקשות ההרחבה בעתיד לכיוון שטח שכן אחר תחייבנה את הסכמת השכן כדי לשמור על עקביות בדבר אי-פגיעה בזכויות שכנים.
2. נטען בכתב-התביעה כי הבית, שאינו רשום בפנקס הבתים המשותפים סובב בחצר אותה הסכימו בעלי 4 הדירות לחלק ביניהם בפועל על ידי גדרות. התובעים בנו גדר אבן על תוואי גדר חיה שהפרידה בין שני חלקי החצר העורפית, בניה שלא קיבלה היתר. לטענת התובעים יש לייתן היתר חרף התנגדות השכנים לנוכח החלוקה המוסכמת מזה שנים.
3. נתבעים מס' 1 שהם בעלי הדירה מתחת לדירת התובעים טענו כי לשום דירה לא הוצמד חלק מסוים של חצר הבית וכי לכולם חלקים בלתי מסוימים ברכוש המשותף. במידה שהיתה חלוקה של החצר אזי היא נועדה לשם הקלה על תחזוקה שלה מהטעם שבבית לא היתה נציגות מכהנת. מעולם לא היתה הסכמה בבית המשותף לבניה בשטח כלשהו של החצר. התובעים ביצעו יציקת משטח בטון בשטח החצר ובשלב מאוחר יותר הקימו גדר לבנים בחצר, מה שפוגע באופן ממשי בחזות הבית המשותף. לטענת נתבעים אלה

מעולם לא היתה קיימת בחצר העורפית כל גדר שהיא, לא חיה ולא בנויה. הנתבעים מתנגדים לקיר האבן בהיותו פוגע באיכות חייהם ובזכויותיהם הקנייניות. הקיר מהווה מטרד כמו גם השימוש שעושים התובעים במשטח הבטון. לאור המקובץ דורשים הנתבעים כי התביעה תידחה וכי יינתן נגד התובעים צו להרוס את גדר האבן ואת משטח הבטון שנבנו שלא כדין.

4. נתבע מס' 2 טוען כי למעט ההסכמה לאפשר לכל בעל דירה לבנות מחסן בירכתי החצר לא היתה מעולם הסכמה להקנות שימוש ייחודי בחלק כלשהו ממנה למי מבעלי הדירות. במידה שהוא עושה שימוש בחצר הסמוכה לדירתו אזי השימוש הוא על בסיס הסכמה שהתגבשה לפני עשרות שנים בין מי שהיו בעלי הדירות בשעתו. הגדר שהקימו התובעים מכערת את הבית ומביאה לידי תפיסת חזקה ייחודית בשטח העולה באופן ניכר על רבע משטחי החצר המשותפת. מנימוקים אלה הוא דורש כי התביעה תידחה.

5. לא נתקבל כתב-הגנה מטעם נתבע מס' 3 וספק בעיני אם ההמצאה של כתב-התביעה היתה כדין. יחד עם זאת, מאחר וראיתי לדחות את התביעה מנימוקים כמפורט להלן, לא ראיתי כי תינזק זכות של נתבע זה.

6. הבית המשותף הנדון נמצא ברחוב הקיבוצים 9, קרית-חיים ומזוהה כחלקה 127 בגוש 11583. הבית אינו רשום כבית משותף וברי לכן כי לא הוצמדה שום חלקת קרקע של חצר הבית לאיזו מהדירות בו. בעלי המקרקעין היא הקרן הקיימת לישראל. על פי כתבי-הטענות מונה הבית 4 דירות. הצדדים להליך זה הם חוכרי כל הדירות.

7. בכתב-התביעה ביקשו התובעים, למיטב הבנתי, פסק-דין הצהרתי לפיו הם זכאים להותיר את גדר האבן שבנו בחצר העורפית ואת משטח הבטון על מכונם. אבהיר כי הדיון בפני הינו על בסיס חובות וזכויות של בעלים וחוכרים בדירות בבית משותף תוך יישום המבחנים שנקבעו בפסיקה למימוש זכויות קנייניות בבית משותף. אין לדיון בפני ולא כלום עם ערכאות הרישוי לכל בניה שהיא.

8. כדי להתרשם מהנטען קיימתי ביום 28.7.04 ביקור במקום. אני מוצאת להדגיש את הנתונים הרלוונטיים הבאים:

(א) מדובר כאמור בבית משותף המונה 4 דירות: שתי דירות בקומת קרקע ושתי דירות בקומה א'; שתי דירות בחזית הבית ושתי דירות בעורפו. בין חזית לעורף ממוקם חדר מדרגות משותף אליו מגיעים באמצעות מדרכה שנמתחת מהמדרכה הציבורית בואכה חדר המדרגות. אותה מדרכה ממשיכה אל עורף החצר שם ממוקמים מספר מחסנים שאינם נושא הדיון.

(ב) המירווח הקדמי בין הבנין למדרכה הציבורית צר בהרבה מהמירווח האחורי. המירווחים הצידיים אף הם צרים עוד יותר.

(ג) נתבע מס' 2 הינו החוכר והמחזיק בדירת הקרקע החזיתית. מתחם הקרקע הסובבת את דירתו מגודר, בקטע בין חזית דירתו לבין המדרכה הציבורית קיים ריצוף מקורה וסוגר עליו שער.

(ד) קיימת גם גדר רשת נמוכה סביב החצר הסובבת את דירת נתבע מס' 3 אך קיימת אליה אפשרות גישה באמצעות פתח באותה גדר.

(ה) בעורף המבנה חצר רחבה. פונים אליה שני חלונות של דירת הקרקע, דירתם של, הנתבעים, וכן המיפתחים של דירת התובעים שבנויה מעל.

(ו) לדירת התובעים בוצעה תוספת בניה כלפי גג הבית.

(ז) במירווח בין מיתחם המחסנים שבירכתי החצר לבין הקיר האחורי של הבית משתרעת החצר העורפית של הבית.

(ח) בכמחצית החצר העורפית יצוק משטח בטון, עד מרחק כ-1.5 מ' לכל היותר (עפ"י מראית עין). המחצית האחרת מהווה קרקע חשופה. על הגבול בין הקרקע החשופה לבין המשטח היצוק, בניצב לקיר הבית, בנויה גדר בלוקים בגובה של כ-1.2 מ' אשר ממשיכה כדי 60 ס"מ לערך במקביל לבית תוך שהיא "סוגרת" על המישטח.

9. כל אחד מהצדדים סיכם טענותיו וכן המציא מסמכים כפי שמצא לראוי. בכתב הסיכומים בעצם חזר כל צד על עיקרי טענותיו:

(א) התובעים מזה הדגישו את החלוקה בפועל של חצר הבית בין הדיירים, וראיה לכך החצר המשמשת את דירת נתבע 2 בלבד, נטיעת עצים כל אחד בחלקו, הקמת מחסנים, את הגידור בשיעור שאינו עולה על החלק היחסי שלהם ברכוש המשותף, ואת ההבטחה כי לא יהיה במשטח האמור כדי למנוע הרחבת דירת הנתבעים 1 אם יחפצו בכך.

(ב) הנתבעים מס' 1 מזה הדגישו את עשית הדין העצמית של התובעים מבלי שנטלו רשות והסכמה ממי מיתר הזכאים לזכויות קנייניות בבית המשותף באופן שפוגע בדירתם שלהם ואין להתיר זאת.

(ג) הנתבע מס' 2 טען כי השימוש שהוא עושה בחצר הסובבת את דירתו לא מונעת שימוש מדיירים אחרים, מדובר בגידור, ריצוף וקירוי שנעשו לפני עשרות בשנים בהסכמת מי שהיו אז בעלי הזכויות בדירות הבנין.

10. כפי שכבר נאמר לעיל לא השתכנעתי כי התובעים זכאים לסעד לו עתרו בכל הנוגע לגדר ולמשטח הבטון. אלה נימוקי החלטתי:

(א) התובעים אינם טוענים כי היתה הסכמה לבניה שהם ביצעו ודומה כי על כך אין מחלוקת. הם גם אינם מכחישים שהמדובר ברכוש משותף (ואפילו הכחישו אזי הרישום בפנקס המקרקעין הוא המחייב). בפיהם הטענה כי חרף כל אלו מן הדין להתיר להם לנהוג בחלק החצר התואם את החלק היחסי שלהם ברכוש המשותף מנהג בעלים כשם שנוהגים דיירים. אחרים וכשם שנוהג הבית מזה שנים.

(ב) אלא שהתובעים נתפסו לכלל טעות: לא הרי שימוש כהרי בניה ברכוש המשותף. אפשר שאכן התגבש נוהג במהלך השנים לפיו השימוש בחצר חולק בין הדיירים אך לא בוצעה שום בניה המקבעת מצבים. שימוש מאפשר גמישות ושינוי לפי נסיבות כל מצב חדש. כך, למשל, אפילו היתה חלוקה היסטורית מוסכמת של החצרות אין בה כדי למנוע הרחבת דירה גם לא בתחומי החלוקה ההיסטורית מקום שניתן היתר בניה ומימושו, לנוכח מיקומו של הבניין על החלקה, אפשרי בחזית שונה מזו של החלוקה ההיסטורית. שינוי נסיבות כזה טורף את החלוקה ההיסטורית.

(ג) יתירה מכך, שימוש ברכוש משותף חובה שיהיה, לפי הפסיקה, סביר. שימוש סביר הוגדר בפסיקה כשימוש העולה בקנה אחד עם תנאי המקום והזמן. ראה פס"ד וינטרס נ. זמורה ע"א 549/73 פד"י כח (1) 645:

"אם לפי התקנון החל על הבית המשותף או לפי החלטה מוסמכת של האסיפה הכללית נועד חלק כלשהו מהרכוש המשותף למטרה פלונית, לא יוכל בעל דירה להשתמש במקום זה למטרה אחרת שאינה מתישבת עם המותר. אבל, לדעתנו, בהעדר יעוד אין בעל דירה חוטא כלפי בעלי הדירות האחרים כשהוא עושה ברכוש המשותף שימוש יום-יומי רגיל ומתאים למקום".

(שם עמ' 647)

(ד) יציקת משטח הבטון כמו גם הקמת גדר האבן לחלוטין אינן מהוות שימוש העומד במבחנים הללו. קירבת הבניה לקיר הבית, למפתחי דירת נתבעים 1 באופן המחייב היצמדות לקיר הבית כדי לעבור לצידה האחר של החצר העורפית, ושינוי פני החצר, כל אלו שוללים את הבניה מהיותה בבחינת "שימוש סביר".

(ה) אם תאמר כי שיקול דעתה של הערכאה השיפוטית מצומצם יותר מקום שהיתה התנהגות דה פקטו משך שנים של בעלי הדירות אפנה לפסק דינו של כב' השופט טירקל ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פד"י נה(1), 199 שכתב את חוות-דעת הרוב בפסק-הדין האמור, ומנה ארבעה שיקולים עיקריים אשר ראוי כי ינחו את הפעלתו של שיקול הדעת השיפוטי כאשר באים להגביל את בעל זכות הקנין מלממש את זכותו:

"השיקולים העיקריים אשר לדעתי ראוי שינחו את הפעלתו של שיקול הדעת בבואנו להגביל את בעל זכות הקניין מלממש את זכותו ... השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה, השיקול השני הוא עצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה, השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות, השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי הדין ... ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית-המשפט עד בלי השאר לו שריד".

ובהמשך -

" ... נראה לי כי יש להיזהר מהרחבה יתרה של שיקול הדעת כאשר מדובר במניעת מימוש של זכויות קניין ... זאת בעיקר כאשר הפעלתו של שיקול הדעת מתבקשת כדי לכבול את ידיו של בעל הזכות ולמנוע ממנו להתגונן מפני פגיעה שלא כדין בזכותו ..."

(1) יישום המבחנים הללו על עובדות המקרה הנדון מחייבים דחית התביעה: כפי שהתרשמתי מהביקור במקום זכותם הקניינית של הנתבעים מס' 1 נפגעת באופן מובהק כתוצאה מהבניה. וזאת יש לאמר כי פגיעה בדירה מהסוג שהחוק אינו מתיר אם לא באה הסכמה מפורשת ומוקדמת לה, מוגדרת בסעיף 2 לחוק המקרקעין ככזו הפוגעת בחזות החיצונית התקינה והאחידה, המסכנת או עשויה לסכן את קיומה של הדירה האחרת, משנה או עשויה לשנות את ערכה. הבניה מאפשרת, בשל הגבהת מפלס הקרקע, תצפית לתוך דירת הנתבעים הללו, הקירבה לחלונם היא בלתי סבירה וללא ספק פוגעת בערך הדירה.

(2) הקמת המשטח וגדר הבלוקים באופן (חרף התנגדות הנתבעים מס' 1) ובמקום בו הוקמו (למול חלון דירתם ובקירבה בלתי סבירה) משקף אפילו מדה מסוימת של חוסר תום לב כמשמעות מונח זה בפסיקה. ראה דבריו של כב' הנשיא באותו פסק דין רוקר בסוגית תום הלב המתבקשת מבעל דירה המבקש לממש זכות קניינית בבית משותף, לאמור:

" ... כל זכות (במובן הרחב) המוגנת בחוק המקרקעין צריכה להיות מופעלת בתום-לב; כל חיוב המעוגן בחוק המקרקעין צריך להתבצע בתום-לב ... כך למשל זכותו של כל שותף במקרקעין כלפי שותפיו האחרים צריכה להיות מופעלת בתום-לב ... מתכולתו של עקרון תום הלב על השימוש בזכויות (במובן הרחב) על פי חוק המקרקעין מתבקשות מספר מסקנות: ראשית, השימוש בזכויות ... צריך להיעשות מתוך

הגינות. מושג תום-הלב בהקשר זה משמעו אמת מידה אובייקטיבית. לא נדרש ... כי בעל הזכות יפעל מתוך זדון או רוע לב. די בכך שפעולתו אינה עולה בקנה אחד עם "הערכים הראויים של החברה הישראלית כפי שבית-המשפט מבין אותם מעת לעת" ...; שנית, השימוש בזכות כולל בחובו גם הגשתה של תביעה ... הן הזכות והן כוח התביעה בגין הזכות כפופים לעקרון תום-הלב; שלישית, תום-הלב חל על כל שימוש בזכות, בין שימוש בזכות הקנין הגורם נזק לזולת לבין שימוש בזכות הקנין שנועד להגן על זכות הקנין מפני מתנכלים לה; רביעית, לשופט נתון שיקול דעת בגדרי המרחב הניתן לו מכוח פעולתו של עקרון תום-הלב בהענקת סעדים הפוגעים בזכויות על פי חוק המקרקעין. היקפו של שיקול דעת זה נגזר מעוצמת פעולתו של עקרון תום-הלב".

11. משמצאתי כי דין התביעה נגד נתבעים מס'1 להידחות וכי התובעים אינם זכאים כי ניתן לזכותם פסק הדין ההצהרתי לו עתרו אין עוד צורך לדון בעמדות יתר הנתבעים.

12. לא ראיתי שום קשר בין הבניה על הגג לבין המחלוקת כאן. הבניה על הגג תאמה היתר בניה שניתן, לא התגלעה סביבה מחלוקת משפטית ולפיכך אינה רלוונטית. במידה שיש בה רלוונטיות אזי היא קיימת לענין ההוכחה כי כאשר מדובר בבניה, להבדיל משימוש שאינו משנה את אופי המיתחם המשותף, אזי היא מותנית בהסכמה או בהכרה שיפוטית. הבניה משקפת את החלקים היחסיים של דירת התובעים ברכוש המשותף, ואם נותרו לזכותם אחוזי בניה אפשר שיוכלו לממש אותם מעל תוספת בניה שיבצעו הנתבעים 1. הוא אשר אמרתי, נושא זה אינו עומד כאן להכרעה.

13. נתבע מס' 2 אכן תפס חזקה ייחודית בחלק החצר הסובבת את דירתו, אפשר שמתוך הסכמה שניתנה לו לפני שנים במפורש או במשתמע על דרך של התנהגות. הסכמה לא רק לשימוש אלא גם לבניה היינו ריצוף וקירוי. אין באותה בניה עתיקת יומין כדי להעיד על הסכמה לבניה כוללת לרבות זו של התובעים שנעשתה זה מקרוב. נהפוך הוא; אילו הוסכם בשעתו כי כל בעלי הזכויות יתחמו את חצרותיהם היה הדבר מבוצע. אם אכן היה תיחום באמצעות גדר חיה תקינה וברורה ערב בנית גדר האבן אפשר שהיה מקום להתיר חידושה, אך לא הוכח לי כי זה היה המצב וכן לא נתבקש סעד לכך.

14. אני דוחה אפוא את התביעה על כל חלקיה.

15. אני מחייבת את התובעים יחד ולחוד לשלם לכל אחד מהנתבעים 1, 2, הוצאות משפט כולל שכר טירחת עורך דין סך של 3,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (24.5.04) ועד התשלום המלא בפועל.

16. אינני נענית לסעדים להם עתרו הנתבעים באשר היא באה במסגרת כתב ההגנה.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ד' כג' בשבט תשס"ה (2.2.05)
העתקים יישלחו לצדדים.

צפורה פיגנבוים
מפקחת על רישום מקרקעין